

1517569-66.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517569-66.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517569-66.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212284/2022 - 73º D.P. JACANA, 26565828 - 73º D.P. JACANA, 2212284 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Henrique Avelino De Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S.

HENRIQUE AVELINO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 129, §12º e art. 329, caput, todos na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 20h20min, na Rua Francisco Alves Bezerra, altura do numeral 379, Parque Edu Chaves, nesta capital, tinha em depósito, para fins de tráfico, 66 porções de "Cannabis sativa L.", substância vulgarmente conhecida como "maconha" (350,3g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E ainda porque nas mesmas circunstâncias de tempo e local, se opôs à execução de

ato legal, mediante violência física contra os policiais militares Renan Mangili de Melo e Ariclenys José da Silva, competentes para executá-lo; bem como ofendeu a integridade corporal do policial militar Renan Mangili de Melo, quando este se encontrava no exercício de sua função.

Segundo a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na região dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando visualizaram HENRIQUE e mais dois indivíduos não identificados, sendo que estes últimos, tão logo notaram a presença policial, evadiram-se correndo. HENRIQUE, por sua vez, estava colocando uma sacola sobre o pneu de um Fiat/UNO, sem placas, que estava em aparente estado de abandono estacionado na via pública anteriormente indicada e, ao perceber a presença policial, saiu do local caminhando.

Os dois indivíduos não identificados conseguiram fugir, enquanto HENRIQUE foi abordado.

Ocorre que, durante a abordagem, HENRIQUE resistiu e passou a se “debater” e gritar, com a intenção de fugir, ocasião em que mordeu o braço esquerdo do policial Renan, razão pela qual precisou ser contido pelos policiais.

Ainda durante a diligência, os policiais revistaram o automóvel Fiat/UNO acima apontado e encontraram, sobre o pneu traseiro, a sacola anteriormente manuseada por HENRIQUE, que continha em seu interior 22 (vinte e duas) porções de “maconha”.

Apurou-se ainda que, em frente ao automóvel Fiat/UNO, também foi localizada uma sacola contendo mais 44 (quarenta e quatro) porções de “maconha” e a quantia de R\$ 1.075,00 (mil e setenta e cinco reais) em espécie (comprovante de depósito a fls. 58).

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 45/48.

Pela celeridade processual, o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2022 (fls. 82/84).

O réu foi citado (fls. 102/103), foi apresentada resposta à acusação (fls. 104/105) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 118).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, após o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de memoriais, a representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a procedência total da ação para condenar o réu nos termos da denúncia (fls. 125/133).

A Defesa, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório no tocante ao delito de tráfico de entorpecentes e com a atipicidade dos crimes de resistência e de lesão corporal, pelo que postulou sua absolvição.

Subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 37 da Lei nº 11.343/06, a aplicação do princípio da consunção no que tange aos delitos de resistência e lesão corporal, a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, a sua compensação com a agravante da reincidência, a fixação de inicial aberto ou semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 135/143).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição de apreensão de fls. 11/12 e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/08, bem como pelos laudos periciais de fls. 14/16 (constatação), fls. 63/65 (entorpecentes) e fls. 59/62 (IML réu e vítima policial).

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para TETRAHIDROCANNABINOL (THC), listada entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 6365), corroborando o auto de constatação de fls. 14/16.

A autoria dos crimes pelo réu, outrossim, restou demonstrada pela prova oral coligida nos autos.

O réu, na fase inquisitiva, permaneceu silente (fls. 05).

Em Juízo, estava no local com outras duas pessoas, estava trabalhando no tráfico como "olheiro", avisou os outros dois, tentou andar, mas não tinha droga com ele, o policial já veio lhe batendo, quando o policial Renan veio, lhe jogou no chão, não o mordeu, estava roxo sem ar, desmaiou e quando viu já estava dentro da policial. Não conhecia os policiais antes. A droga estava no pneu do carro, mas não mexe nas drogas, só viu no pneu de trás. Não sabe se a outra sacola também era do tráfico. Estava ganhando 200,00 por dia, mas das 7h até meia-noite. Só tinha que avisar a chegada dos policiais. Já tinha sido processado por tráfico, estava em regime aberto, terminaria em agosto.

A versão do acusado, contudo, restou isolada no conjunto probatório produzido, e a ele incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O Policial Militar Renan Mangili de Melo, reconhecendo o réu em audiência, disse que estavam em patrulhamento e quando chegaram em um cruzamento, viram três pessoas na lateral de um carro, o réu e mais dois, estava baixado atrás de um Fiat Uno branco abandonado, ele estava do lado da calçada.

Foram abordar os três, dois correram, foi correndo atrás, e não conseguiu abordar, o Sargento foi até o réu para abordá-lo. O réu andou, começou a tentar se desvencilhar, entraram em luta corporal, ele lhe mordeu o braço, ele incitou a população que tentaram tirar de sua posse, conseguiram imobilizar pneu traseiro direito uma sacola branca com 22 porções e na frente uma sacola com R\$1.750,00 e mais 44 porções de droga. Ele estava abaixado na porta de trás do carro, na roda, e os demais de pé. O dinheiro estava junto com as drogas. O local é ponto conhecido de tráfico de drogas. Não conhecia o réu antes dos fatos. Ele estava abaixado mexendo na roda quando passaram, ele falou algo para os outros que estavam com ele e saiu andando o veículo estava mais para frente, viram que ele estava mexendo na roda e quando foi verificar, viram a sacola. Ele andou no sentido contrário da viatura, para trás do carro. O sargento estava mandando parar, ele estava de pé se debatendo para tentar sair da camiseta que o sargento estava segurando sua camiseta. A população no local sempre investe contra os policiais para livrar as pessoas, foi o que tentaram fazer no caso com o réu também.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Civil Ariclenys José da Silva, que também reconheceu o acusado e acrescentou que também não conhecia o acusado antes dos fatos e que ele esboçou uma tentativa de fuga, mas conseguiu abordá-lo, agarrando-o e então entraram em luta corporal. A sacola do pneu onde o réu estava abaixado era branca e a da frente do carro era rosa.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem reboços, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Não há nenhuma prova, além da palavra do réu que ele era apenas o "olheiro" do ponto de tráfico. Os policiais afirmaram que o acusado estava mexendo na sacola onde estavam as drogas, agachado, não havendo motivos, como já dito, para se duvidar da conduta dos policiais, os quais nem mesmo o réu conhecia.

A quantidade de droga encontrada é grande e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidos, um total de 66 porções de "Cannabis sativa L.", substância vulgarmente conhecida como "maconha" (350,3g); sendo capazes de produzir mais de 1.251 cigarros de "maconha", e assim, suficientes para o comprometimento de um número grande de usuários.

Ademais, foi apreendida quantia em dinheiro em poder do acusado (fls. 11 - R\$ 1.075,00).

Logo, tudo nestes autos revela que o réu tinha em depósito as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Ademais, também restou comprovado que o acusado se opôs à execução de ato legal,

mediante violência contra os policiais militares competentes para executá-lo, vez que ao ser abordado resistiu se debatendo; tendo, ainda, lesionado o policial Renan (mordendo o seu braço esquerdo, inclusive causando-lhe lesões corporais leves, conforme laudo pericial de fls. 61/62).

Com tais condutas, o acusado praticou ações típicas previstas nos arts. 129, §12º e art. 329, caput, ambos do Código Penal.

Não há se falar em atipicidade da conduta do acusado com relação aos crimes de resistência e de lesão corporal, tendo em vista que as agressões dele contra o policial, comprovadas por laudo pericial, se subsumem aos tipos penais acima citados, não sendo caso de legítima defesa como alega a defesa.

Outrossim, melhor estudando o assunto e e revendo posicionamento anterior, inclusive apontado pela defesa, entendo que “incogitável a absorção do delito de lesão corporal leve pelo de resistência, sendo inaplicável, na espécie, o princípio da consunção, por expressa previsão do artigo 329, §2º, do Código Penal (...) tendo em vista que a violência contra a pessoa deve ser sempre punida com rigor, o tipo penal prevê, como em várias outras oportunidades, o sistema da acumulação material, isto é, o agente responde pela resistência e pelo que causou à vítima” (TJSP; Apelação Criminal 1501010-85.2021.8.26.0481; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/08/2022; Data de Registro: 23/08/2022).

Inafastável, assim, a condenação do réu nos termos da denúncia.

Isso porque, a despeito das alegações da defesa, restou comprovado nos autos que o acusado praticou os delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 129, §12º e art. 329, caput, ambos do Código Penal, não bastando as filmagens de fls. 117 como prova capaz de afastar a responsabilidade do acusado, até porque em tais imagens sequer é possível identificar o réu e os policiais envolvidos nos fatos objeto destes autos. Ademais, nenhuma testemunha foi arrolada pela defesa que pudesse corroborar a versão do acusado e tais filmagens.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O acusado é reincidente por tráfico (fls. 33/36).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, para o crime de tráfico, três meses de detenção para o delito de lesão corporal leve e dois meses de detenção para o delito de resistência.

Não há atenuantes a serem reconhecidas.

Pela reincidência de rigor a exasperação da pena em 1/6, totalizando cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa, para o crime de tráfico, três meses e quinze dias de detenção para o delito de lesão corporal leve e dois meses e dez dias de detenção para o delito de resistência.

Deixo, outrossim, de aplicar a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos em razão da reincidência do acusado, bem como porque a quantidade de drogas apreendidas – 66 (sessenta e seis) porções de “Cannabis sativa L.”, substância vulgarmente conhecida como “maconha” (350,3g) -, obstam o reconhecimento do redutor, não sendo suficiente para sua aplicação simples preenchimento dos requisitos objetivos do dispositivo legal. “Há, também, necessidade da fiel observância do que estabelece o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao aludido dispositivo, até mesmo a negativa da redução.” (TJSP, 14ª Câmara da Seção Criminal, Apelação Criminal nº 0021791-35.2010.8.26.0176, Relator Desembargador Marco de Lorensi, J. 11/11/2011, negaram provimento, v.u).

Insta salientar, nesse ponto, que a valoração da reincidência na segunda fase da dosimetria, bem como nesta última para afastar o citado redutor não configura bis in idem. Nesse sentido, cito o trecho do voto do Desembargador Sergio Coelho:

“não há qualquer violação aos princípios da proporcionalidade, isonomia ou do ne bis in idem na utilização da recidiva como agravante genérica e, ao mesmo tempo, para afastar a causa especial de diminuição de pena, por se tratar de fases distintas da dosimetria e gerarem efeitos diversos. Confira-se, a respeito, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: (...) Não há que se

falar em bis in idem quando considerada a reincidência na segunda etapa da dosimetria, como agravante genérica, e na terceira fase de aplicação da pena, como impeditivo para o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois se trata apenas de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação da reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e à reprovação do delito, nas circunstâncias em que cometido. (HC nº 178.933/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma". (TJSP; Apelação 0000218-53.2017.8.26.0577; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).

De se destacar, ainda, o entendimento jurisprudencial, em brilhante voto de lavra do Exmo. Desembargador do TJSP, Luis Soares de Mello, a aplicação do redutor é facultativa, consoante a letra da Lei, e deve ser analisada a cada feito: "Na terceira fase de aplicação da reprimenda, deixou-se, de forma acertada, de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Isto porque, nada obstante tenha a novel legislação anti-drogas (Lei nº 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui considerá-la mais benéfica e em favor do acusado ("lex mitior"), porque meramente facultativa a situação ("...as penas poderão ser reduzidas..." g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o caso concreto, muito mais aqui, evidentemente, face à considerável quantidade, diversidade e poder vulnerante dos poderosos entorpecentes encontrados em poder do acusado, além das circunstâncias da prisão daquele, possível apenas diante do recebimento da denúncia anônima, o que demonstra que o réu já vinha praticando a atividade ilícita há algum tempo. O que denota habitualidade constante e reiterada, a demonstrar que o réu não pode ser tratado igualmente a outros." (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

Considerando que o delito de lesão corporal foi praticado contra policial militar, isto é, agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função, nos termos do §12º do art. 129 do Código Penal, exaspero a pena do delito de lesão corporal em 1/3, totalizando quatro meses e vinte dias de detenção.

Pelo concurso material de crimes, somo as penas impostas, totalizando cinco anos e dez meses de reclusão, sete meses de detenção, e pagamento de 583 dias multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu HENRIQUE AVELINO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 129, §12º e art. 329, caput, todos na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de cinco anos e dez meses de reclusão e sete meses de detenção, e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 583 dias-multa, com unidade no mínimo legal. O réu não faz jus a qualquer benefício, dada a pena aplicada, bem como a hediondez do delito pelo qual é acusado, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: "(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial" (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado, tendo em vista a pena aplicada, a reincidência do acusado, a hediondez do delito pelo qual é condenado e a necessidade da prevenção do tráfico de drogas, que se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei. Neste sentido:

"Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e

cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dês que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir." (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

E ainda:

O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos. O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais. Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas. Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave. Mas há os considerados hediondos. Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável. Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado? O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o "crack", por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo. A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social. O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados. Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminoso, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias. Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa. O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal como procedeu o Legislativo. Bem por isso que a

substituição por restritivas de direito é absolutamente inadmissível. Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive! O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de que se trata de crime gravíssimo. Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Em liberdade, ou mesmo em regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0084044-40.2016.8.26.0050, Relator Desembargador Poças Leitão, São Paulo, negaram provimento, v.u., j. 30/11/2017 - grifei).

E mais, a reincidência do acusado e esta nova condenação indicam nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido:

"tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal" (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

E ainda:

"Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes" (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

"Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta" (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Por outro lado, em atenção ao disposto no art. 33, caput e §§2º e 3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena de detenção em regime semiaberto, desde que compatível com eventuais outras condenações. Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, a sua reincidência e reiteração criminosa, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA